

1500327-17.2021.8.26.0556

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sergio Augusto de Freitas Jorge

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIOGO BAFFA

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Sergio Augusto de Freitas Jorge

Vistos.

DIOGO BAFFA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, c.c. o art. 61, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

2ª Vara Criminal

Rua dos Libaneses nº 1998

CEP: 14801-425 - Araraquara - SP

Telefone: (16) 3336-1034 - E-mail: araraq2cr@tjsp.jus.br

1500327-17.2021.8.26.0556 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500327-17.2021.8.26.0556

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIOGO BAFFA

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Sergio Augusto de Freitas Jorge

Vistos.

DIOGO BAFFA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, c.c. o art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, pois, no dia 22 de maio de 2021, por volta das 10:00 horas, durante estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 06/2020), na Avenida Leonardo Gomes, nº 1262, Jardim Roberto Selmi Dei, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para fins de mercancia, 24 porções de maconha, com peso líquido de 61,91 gramas, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificado o réu (fl. 140) e apresentada defesa preliminar (fls. 144/145), a denúncia foi recebida (fls. 146/147). O acusado foi citado (fl. 161).

Na fase de instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela Acusação, sendo o réu interrogado ao final (fls. 164/167).

Em debates orais, a DD. Representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado, ao passo que o Ilustre Defensor Público postulou a sua absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06 ou, em caso contrário, o afastamento da majorante contida na denúncia e o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, bem como a aplicação do privilégio, com a fixação da pena no mínimo legal, em regime prisional inicial aberto, e a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos (fls. 164/167).

É o relatório.

DECIDO.

A acusação é parcialmente procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva foi aferida sobretudo pelo teor do auto de exibição e apreensão (fl. 11) e dos laudos de constatação provisória (fls. 13/15) e definitiva de entorpecentes (fls. 108/110), com resultados positivos para THC (maconha).

A autoria do delito, por seu turno, foi evidenciada pelo conjunto da prova oral colhida no curso da ação penal e pelos demais informes coligidos na fase inquisitiva.

Em sede policial, o acusado negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, afirmando que na ocasião fora ao local dos fatos apenas para adquirir drogas para o seu consumo pessoal (fls. 04 e 111/112).

Em juízo, manteve tal versão e aduziu que, na data dos fatos, estava no local em questão com sua tia quando avistou a aproximação dos policiais militares e saiu correndo. Negou ter dispensado algo antes de sua abordagem e admitiu apenas a propriedade de 3 porções de maconha que havia acabado de comprar pelo valor unitário de R\$ 10,00, as quais eram destinadas ao seu próprio consumo. Atribuiu o

restante da droga a um traficante de nome Geraldo. Esclareceu que, na ocasião, o menino que lhe vendera o entorpecente se evadiu no momento da aproximação da viatura policial e não foi abordado. Negou qualquer envolvimento com o narcotráfico, mas confirmou que na adolescência já fora internado na Fundação CASA em razão dessa prática. Declarou-se usuário de maconha e atualmente trabalha como ajudante de pintor. Disse sentir-se perseguido pelos policiais que o abordaram na ocasião (cf. gravação audiovisual de fls. 164/167).

Ocorre que, apesar da versão exculpatória exarada pelo réu nas ocasiões em que ouvido, o arcabouço probatório coligido durante a persecutio criminis contém elementos seguros e aptos a demonstrar a sua responsabilidade, na espécie.

Assim é que os policiais militares Godói e Souza Júnior relataram que, na data mencionada, durante patrulhamento pelo local dos fatos, já conhecido pelo frequente comércio de drogas, visualizaram o acusado sozinho, em atitude suspeita. Ao notar a aproximação da viatura policial, ele dispensou algo no chão e saiu correndo em direção a uma estrada de terra. Efetuaram então a sua abordagem, pois já era conhecido no meio policial pelo envolvimento com o tráfico de entorpecentes, mas nada de ilícito foi com ele localizado. Não havia outras pessoas por perto do réu no momento da abordagem. Constataram que o objeto dispensado era um invólucro plástico contendo 24 porções de maconha acompanhadas de papel de seda, sendo que junto a cada uma delas também havia uma bala Freegells. Indagado, o acusado inicialmente negou a prática do narcotráfico, mas depois passou a afirmar que havia recebido o entorpecente de um tal Geraldo, traficante e morador daquela região, e que realizaria a respectiva venda naquele local. Ele ainda lhes revelou que a bala era utilizada como um diferencial para atrair a clientela devido à forte concorrência no local (cf. gravação audiovisual de fls. 164/167).

Souza Júnior ainda confirmou que o tal Geraldo é conhecido no meio policial como um traficante daquele bairro, mas não foi localizado nem identificado na ocasião.

Como se vê, o quadro probatório é sólido e não deixa dúvidas acerca da conduta delituosa do réu. Os elementos de convicção colhidos na fase policial e em juízo revelam-se firmes e substanciais, apontando-o com segurança como agente criminoso, no caso vertente.

Na hipótese em exame, a conclusão de que a droga apreendida se destinava ao comércio ilícito e ao fornecimento a terceiros é obtida sobretudo pela natureza e forma de acondicionamento do tóxico (24 invólucros plásticos contendo maconha, com peso líquido total de 61,91 gramas - cf. auto de fl. 11 e laudos de fls. 13/15 e 108/110 -, já separados individualmente para a revenda e entrega a terceiros, cf. fotografia de fl. 15).

Antes de se evadir correndo, o imputado - indivíduo já conhecido por seu envolvimento com o narcotráfico desde a adolescência - foi flagrado pelos castrenses dispensando algo no chão, constatando-se em seguida tratar-se de um invólucro plástico contendo as 24 porções de maconha embaladas individualmente.

Note-se que, ao ser abordado, o réu admitiu aos castrenses atuantes na ocorrência a finalidade de comercialização do entorpecente apreendido e ainda lhes revelou que a bala Freegells - que acompanhava cada porção da droga - era utilizada como um diferencial para atrair a clientela devido à forte concorrência do narcotráfico naquela região.

Vale ainda gizar, nesse aspecto, que nas circunstâncias em que se deram os fatos não era possível atribuir-se a propriedade da droga a nenhuma outra pessoa, eis que não havia ninguém por perto do acusado no momento em que os milicianos o avistaram e o abordaram.

Revelou-se frágil e inverossímil, assim, a tentativa do réu de atribuir a propriedade do entorpecente a terceiros, que, aliás, não foram sequer identificados ou localizados na ocasião.

Cabe observar, por oportuno, que no meio policial já havia informações dando conta da frequente prática do tráfico de drogas no local dos fatos e nas suas imediações, consoante se infere do teor dos depoimentos dos milicianos ouvidos em solo judicial e dos documentos de fls. 76/77, que apontam a existência de denúncias anônimas alusivas a tal prática ilícita naquelas áreas.

Tais aspectos, examinados de forma conjunta, afastam a veracidade da frágil versão exculpatória exarada pelo réu e confirmam a ocorrência, na espécie, da guarda e do transporte da droga para fins da mercancia maldita.

Sabe-se, outrossim, que, para a configuração do delito de narcotráfico, não se exige qualquer ato de efetiva entrega de droga, bastando que o agente transporte, traga consigo, guarde ou mantenha em depósito a substância entorpecente, sendo inexigível a traditio para fins de consumação do crime (RJTJSP 97/512).

Afasta-se, por conseguinte, a pretensão defensiva de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06, uma vez que todas as circunstâncias do fato acima mencionadas indicam de modo claro e estreme de dúvidas que o entorpecente apreendido era pertencente ao réu e se destinava, efetivamente, à ilícita revenda e ao fornecimento a terceiros – ainda que de forma gratuita -, não sendo unicamente para o uso próprio do imputado.

É consabido, ainda, que a mera condição de usuário de tais substâncias não exclui, por si só, a prática do narcotráfico, pois é fato comum o usuário dedicar-se ao comércio nefasto ou à simples guarda temporária da droga para terceiro a fim de assim quitar suas dívidas com outros traficantes ou mesmo amealhar recursos para poder sustentar o próprio consumo pessoal.

No entanto, é de se afastar, no caso em exame, a majorante prevista no inciso III do art. 40 da Lei nº 11.343/06 – cometimento da infração nas imediações de estabelecimentos de ensino ou hospitalares e outros locais assemelhados -, uma vez que os locais mencionados na denúncia (EMEF Vereador Edmilson de Nola Sá e UPA Nefália de Oliveira Lauar) se situam, respectivamente, a 234 metros e 390 metros de distância do local dos fatos (cf. laudo pericial de fls. 125/128).

Cabe assentar, nesse aspecto, que a expressão “imediações” encerra conceito jurídico relativamente indeterminado, cujo preenchimento o Juiz deve efetuar tendo em vista as circunstâncias do caso concreto e sempre à luz da finalidade do dispositivo, que é proteger tais locais contra as investidas do tráfico. Assim, não há uma medida aritmética. Incide a majorante se o agente pode alcançar, com facilidade e em pouco tempo, os locais especialmente protegidos, o que não ocorre no presente caso, dadas as expressivas distâncias (equivalentes a mais de 2 e 3 quarteirões, respectivamente).

Confira-se a lição de Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi:

“O termo 'imediações' não pode ser convertido em medida aritmética rígida, mas deve ser entendido dentro de critério razoável, em função do perigo maior que a lei procura coibir; as imediações, portanto, abrangem a área em que poderia facilmente o traficante atingir o ponto protegido em especial, com alguns passos, em alguns segundos, ou em local de passagem obrigatória ou normal das pessoas que saem do estabelecimento ou a ele se dirigem” (Lei de Drogas Anotada: Lei 11.343/2006, Ed. Saraiva, 2007, p. 135).

Demonstradas, portanto, a materialidade e a autoria do delito imputado ao réu,

passo à dosimetria das penas a lhe serem aplicadas.

Ante a consideração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, e sendo todas elas favoráveis ao acusado, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na segunda fase da dosimetria penal, não obstante a presença da atenuante genérica da menoridade do réu na data do fato (art. 65, inciso I, do citado codex), suas penas não podem ser reduzidas aquém do mínimo legal (Súmula 231 do Colendo STJ).

Outrossim, embora não haja dúvida de que o crime ocorreu durante o período de calamidade pública decretada em face da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), tal circunstância em nada contribuiu para a prática do delito, razão pela qual, ausente o nexo causal, deve ser afastada a agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Confira-se:

"Na segunda fase do cálculo, é de rigor o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Para exata compreensão do tema, confira-se ensinamento de Guilherme de Souza Nucci: "53. Situação de desgrça particular ou calamidade pública: mais uma vez o legislador pretende punir quem demonstra particular desprezo pela solidariedade e fraternidade, num autêntico sadismo moral, aproveitando-se de situações calamitosas para cometer o delito. Vale-se da fórmula genérica e depois dos exemplos específicos. Constituem os gêneros da agravante: a) calamidade pública: que é a tragédia envolvendo muitas pessoas; b) desgrça particular do ofendido: que é a tragédia envolvendo uma pessoa ou um grupo determinado de pessoas. Como espécies desses gêneros temos o incêndio, o naufrágio e a inundação, que podem ser ora calamidades públicas, ora desgrças particulares de alguém. Ex: durante a inundação de um bairro, o agente resolve ingressar nas casas para furtar, enquanto os moradores buscam socorro." (in Código Penal Comentado, 20ª edição, Editora Forense, 2020, pg. 401). No caso concreto, embora incontestado o estado de calamidade pública, não se verifica que o acusado tenha se aproveitado dessa situação para a prática do crime. A conduta do réu, que já não se encontrava em isolamento social, por ser morador de rua, de subtrair os objetos do interior de um carro estacionado em via pública não se amolda a exemplos hipotéticos de quem se aproveita de uma desgrça particular ou coletiva, como incêndio, enchentes, acidentes automobilísticos, entre outros, para praticar crimes contra vítimas que se encontram em posição de maior vulnerabilidade decorrente dessas situações" (TJSP - Apelação nº 1510214-73.2020.8.26.0228 - 11ª Câmara de Direito Criminal - Rel. Xavier de Souza - j. 14.09.2020).

Por fim, como requerido pelo próprio d. órgão acusatório em alegações finais, sendo o réu primário e portador de bons antecedentes, e não havendo prova de que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, as penas devem ser reduzidas, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (privilégio), no grau máximo de 2/3 (dois terços), perfazendo assim o total de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso mínimo.

Torno as reprimendas, pois, definitivas, diante da ausência de outras causas ou circunstâncias modificadoras.

Insta consignar, por oportuno, que o Colendo Supremo Tribunal Federal já assentara o entendimento no sentido de que o delito de tráfico de drogas, quando há o reconhecimento do privilégio previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não é equiparado a hediondo, nos termos da Lei nº 8.072/90.

De igual modo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, que possuía entendimento sumulado em sentido diametralmente oposto ao acima descrito, cancelou o Enunciado 512 de sua Súmula, alinhando-se à jurisprudência do Pretório Excelso.

E, por fim, recentemente a legislação em vigor veio a contemplar referido posicionamento, consoante se infere do teor do § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal, acrescido pela Lei nº 13.964/19, que dispõe, in verbis:

“Art. 112 (...)

§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.”

Desse modo, a pena privativa de liberdade ora aplicada ao réu será cumprida inicialmente em regime prisional aberto, tendo em vista o quantum da reprimenda e a ausência de circunstâncias capazes de justificar a imposição de regime mais gravoso.

Outrossim, no tocante à substituição da pena carcerária por penas restritivas de direitos, o Excelso Pretório, nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS (Rel. Min. Ayres Britto, j. 01.09.2010), declarou inconstitucional dispositivo da lei que vedava essa conversão (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

E o Senado Federal, em observância à decisão do Colendo STF, por força da Resolução nº 05/2012, suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" contida no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

No caso em exame, faz jus o imputado à substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, conforme previsto no art. 44, § 2º, do Código Penal, já que preenche os pertinentes requisitos legais para a substituição.

Assim, converto a pena corporal acima aplicada em penas de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (arts. 43, inciso IV, e 46, ambos do CP), pelo mesmo prazo da pena reclusiva (art. 55 do CP), e de prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário mínimo em favor de entidade pública ou privada com destinação social desta comarca (arts. 43, inciso I, e 45, § 1º, ambos do mesmo codex), a serem especificadas na fase de execução.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a acusação e CONDENO o réu DIOGO BAFFA à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, com a substituição da primeira por prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e por prestação pecuniária, na forma retroespecificada, como incurso no art. 33, caput, e § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Em caso de descumprimento do benefício da substituição, o regime prisional inicial de cumprimento da pena carcerária será o aberto.

Custas na forma da lei.

P. R. I. C.

Araraquara, 26 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA